

1502754-13.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502754-13.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502754-13.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213856/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, EQ1224-1/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2213856 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

JACKSON SILVESTRE e CARLOS EDUARDO DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta que no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 8h45, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 58, Encruzilhada, Santos, os réus, agindo em concurso de agentes e previamente ajustados, tentaram subtrair, para eles, duas placas de alumínio, com saliência antiderrapante, avaliadas em R\$160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à empresa Innovia Soluções Inteligentes Ltda, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que os acusados se aproximaram do local dos fatos e, com o uso de um alicate e uma chave Philips, passaram a retirar as citadas placas de alumínio de um equipamento de sinalização viária que ali se encontrava para direcionamento do trânsito em razão das obras do VLT.

Consta também, que policiais militares se dirigiram ao local dos fatos, após serem acionados pelo COPOM, ocasião em que visualizaram Jackson arrancando uma placa de alumínio do citado equipamento, enquanto Carlos Eduardo dava cobertura.

Consta por fim, que efetuada a abordagem, os policiais localizaram, no interior de uma sacola que estava em poder de Carlos Eduardo, duas placas de alumínio que já haviam sido retiradas do citado equipamento pelos denunciados, sendo que a pronta intervenção dos policiais militares impediu a consumação delitiva.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 18/20). Auto de Exibição/Apreensão (fls. 04).

A denúncia foi recebida em 12/08/2022 (fls. 83/4).

Os réus foram citados (fls. 154/155 e 156/157) e apresentaram resposta à acusação (fls. 163).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, bem realizado o interrogatório dos acusados (fls. 196/197).

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação penal.

Aduziu que materialidade e autoria restaram comprovadas. Argumentou que as testemunhas policiais afirmaram que cabia a Carlos Eduardo fazer a cobertura do local enquanto Jackson retirava as placas do equipamento. Aduziu que os policiais foram firmes nos seus depoimentos. Sustentou que a negativa de Jackson restou isolada nos autos. Argumentou que ambos réus possuem maus antecedentes e são reincidentes. Afirmou que deve ser aplicada a redução da confissão pelo réu Carlos Eduardo. Pugnou pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

A Defesa, também em alegações finais, pugnou pela improcedência da ação. Afirmou que os fatos são atípicos por falta de potencialidade lesiva da ação dos acusados, pois os bens foram recuperados e a vítima não teve prejuízo. Sustentou que deve ser reconhecida a insignificância da ação dos réus. Sustentou que o valor dos bens era insignificante. Aduziu que os réus não agiram com unidade de desígnio, pois sequer se conheciam, de forma que não agiram em conjunto, não havendo que se falar em concurso de agentes. Afirmou que as condutas dos réus não foram lesivas. Aduziu que não há prova suficientes para a condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 04), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída aos acusados.

A testemunha OSMAR SANTOS FERREIRA, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando recebeu via rádio características de indivíduos que estavam subtraindo peças de um painel luminoso de trânsito. Falou que foi até o local, quando visualizou um dos réus próximo ao equipamento e outro mais distante. Afirmou que os réus já tinham retirados duas chapas de alumínio e estavam retirando a terceira, mas que foram abordados ainda no local. Sustentou que os réus afirmaram que venderiam as placas em um ferro velho. Aduziu que não conhecia os acusados antes dos fatos. Explicou que duas placas já haviam sido retiradas e estavam dentro de um saco preto, mas estavam retirando uma terceira chapa. Afirmou que um dos réus estava no equipamento retirando a chapa e o outro estava ao lado, dando cobertura.

A testemunha ERIC DIAS ROCHA DA SILVA, policial militar, disse que foi radiado via Copom um furto em andamento de uma placa viária eletrônica. Afirmou que se deslocou ao local dos fatos e ao chegar lá viu um dos réus (Jackson) mexendo do equipamento e o outro (Carlos Eduardo) aguardando ao lado, fazendo a visualização do local, dando cobertura, com um saco preto de lixo na mão. Falou que ao chegar bem próximo

viu que um dos acusados estava retirando uma placa e o outro estava segurando, dentro do saco, outras duas placas. Aduziu que quando chegou ao local os acusados estavam retirando uma das peças e o outro estava com as outras duas dentro do saco preto, mas eles não saíram do local. Disse que não conhecia os acusados antes dos fatos e que eles falaram que iriam vender as peças no ferro velho.

O réu JACKSON SILVESTRE, interrogado em Juízo, disse que estava próximo ao local dos fatos e iria ver uma lixeira para pegar material para reciclagem, quando chegaram os policiais e o acusaram de que estaria furtando placas de um equipamento de trânsito. Falou que não conhecia o réu Carlos. Aduziu que não conhecia os policiais antes dos fatos e que não sabe por que eles inventariam essa história. Explicou que já foi processado criminalmente anteriormente. Disse que não tentou furtar os equipamentos e que o réu Carlos estava perto da lixeira. Falou que não estava com qualquer ferramenta.

O réu CARLOS EDUARDO DE JESUS, interrogado em Juízo, disse que tinha saído há pouco tempo da cadeia. Falou que é de Taubaté e que não tinha dinheiro para voltar para a sua cidade. Aduziu que estava com fome e saiu para mexer nas lixeiras, quando viu as placas e foi mexer no local. Falou que conseguiu retirar duas placas e que tentou retirar a terceira. Afirmou que não estava junto com Jackson e que não o conhecia. Aduziu que, quando estava retirando as placas, Jackson estava virando a esquina, quando a polícia chegou. Afirmou que retirou as peças de alumínio para vender.

Diante das provas amealhadas aos autos, verifico que os réus praticaram o delito de furto qualificado mediante o concurso de pessoas, na forma tentada, fato típico previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez que tentaram subtrair placas de alumínio de um equipamento de sinalização de trânsito pertencente à empresa vítima.

Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são contundentes elementos de convicção que respaldam a acusação acerca da prática do crime de furto pelos acusados.

Deste modo, os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que, após serem acionados pelo COPOM para atendimento de uma ocorrência de que indivíduos estavam subtraindo peças de um painel luminoso de sinalização de trânsito, sendo passadas as características dos furtadores, lograram êxito em localizar os acusados no local dos fatos no momento em que um deles estava retirando uma placa de alumínio do citado equipamento, sendo, ainda, que outras duas placas estavam na posse do outro, dentro de um saco preto.

Nesse diapasão, a testemunha Osmar, policial militar que participou da abordagem dos réus, afirmou que foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de furto, quando localizou os dois réus no local dos fatos, um deles retirando uma placa e o outro ao lado, dando cobertura, na posse de outras duas placas já retirada do equipamento. Explicou, ainda, que, assim que chegou ao local, o acusado que estava retirando a placa jogou algumas ferramentas no chão, enquanto o outro que estava ao lado tentou se afastar. Afirmou, também, duas placas já haviam sido retiradas e que os acusados disseram que iriam vender as peças em um ferro velho. Esclareceu, também, que enquanto um dos acusados retirava as placas o outro dava cobertura.

Já a testemunha Eric, policial militar que também participou da abordagem dos acusados, corroborou o afirmado por Osmar, dizendo que foi acionada pelo COPOM para atendimento a uma ocorrência de furto, quando encontrou os réus, um deles retirando uma placa do equipamento e o outro ao lado, dando cobertura, já na posse de outras duas placas de alumínio que tinham sido retiradas. Explicou, também, que era o acusado Jackson quem estava retirando a placa no momento da abordagem e que era o réu Carlos quem estava ao lado, dando cobertura, estando na posse das outras placas. Afirmou que não conhecia os réus antes dos fatos, bem como que os acusados informaram que iriam vender as peças em um ferro velho.

Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu pela eficácia dos depoimentos de agente da lei, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios.

Neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS

E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado." (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Grifei.

Desta forma, a res furtiva foi localizada na posse dos acusados, de modo que a sua apreensão em poder dos agentes implica inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido, o que na espécie não se deu. Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. PENA BEM DOSADA. 1) Absolvição Impossibilidade. Provas suficientes de materialidade delitiva e autoria. Provas orais suficientes à condenação, robustecidas no caso concreto pela clara recalcitrância do acusado à ação da Justiça, o qual, tendo tido a revelia decretada, deixou sponte própria de exercer a faculdade da auto defesa. Bens subtraídos encontrados na posse do acusado em flagrante realizado pela própria vítima. Inversão do ônus da prova. Em tais casos, compete ao réu demonstrar a legitimidade da posse do bem Precedentes jurisprudenciais. 2) Pena bem dosada. Regime fechado adequado. Maus antecedentes. Reincidência. Impossibilidade de regime de início de cumprimento menos rigoroso, indiferente o quantum da sanção..." (TJSP, Des. Alcides Malossi Júnior, AP nº: 0006340-37.2012.8.26.0196).

Assim, não é crível a versão apresentada pelo acusado Jackson de que somente estava próximo ao local dos fatos e que iria ver uma lixeira para pegar material reciclável, sendo acusado injustamente pelos policiais.

Também não merece credibilidade a versão apresentada por Carlos Eduardo, de que ele sozinho estava subtraindo as placas e que Jackson não estava com ele, sequer o conhecendo.

Nesse sentido, as testemunhas policiais foram claras ao afirmar que ambos estavam praticando o delito de furto.

Assim, tanto na fase policial como em Juízo, a testemunha Eric foi clara ao dizer que Jackson era quem estava retirando uma placa, estando na posse de ferramentas, que jogou ao solo quando da chegada dos policiais, enquanto Carlos Eduardo estava ao lado, dando cobertura, bem como de que ele estava na posse de outras duas placas que já haviam sido retiradas.

Não há qualquer arrimo probatório para a tentativa de Carlos Eduardo em tentar eximir Jackson da prática delitiva, pois, conforme já acima fundamentado, as testemunhas policiais foram claras ao descrever a conduta criminoso de ambos os réus, restando demonstrado, inclusive, que era Jackson quem estava retirando a placa de alumínio no momento da abordagem, na posse das ferramentas apreendidas. Também é de se destacar que o delito foi praticado mediante a qualificadora do

concurso de agentes, haja vista que os réus Jackson e Carlos Eduardo praticaram o delito em conjunto, subtraindo para ambos as placas de alumínio retiradas do equipamento de sinalização de trânsito.

Ora, quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada. Por isso, configura-se a qualificadora e a pena é maior. O empenho perpetrado por duas ou mais pessoas é logicamente mitigador da dificuldade na empreitada delitiva, servindo como mecanismo auxiliador da prática criminosa.

No que tange à alegação defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta dos acusados, em razão do princípio da insignificância, pois faltou potencialidade lesiva à ação dos acusados, haja vista que os bens recuperados e a vítima não teve prejuízo, bem como o valor dos era insignificante, esta não merece acolhimento. Desta forma, os réus tentaram subtrair placas de alumínio de um equipamento de sinalização de trânsito pertencente à empresa vítima, de modo que tal atitude não pode ser considerada como insignificante, haja vista que o delito somente não concretizou, sendo os bens restituídos à vítima, por conta da pronta ação policial, de modo que, caso os policiais não tivessem chegado a tempo e terem abordado os acusados durante a prática criminosa, certo seria o prejuízo suportada pela empresa vítima, ressaltado o fato de que os bens subtraídos pertencem à esfera econômica do estabelecimento vítima.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas policiais afirmaram que os acusados, no momento da abordagem, disseram que venderiam as placas subtraídas em um ferro velho, para obter dinheiro, o que ressalta o considerável valor econômico da res furtiva, não havendo que se falar em insignificância do valor dos bens.

Ressalta-se que a aplicação do princípio da insignificância deve se dar em situações excepcionais. É necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, que são: mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, consoante o exposto no HC 84.412/SP, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, situação que não se encontra presente nestes autos.

Destarte, a prevalência da tese defensiva seria um estímulo às subtrações de bens, razão pela qual não tem cabimento a aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Nesse sentido, tem-se:

"FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Não configurada. Confissão que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Princípio da insignificância que não foi recepcionado pela lei penal violação do princípio constitucional da reserva legal. Princípio que não pode ser analisado pelo simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo penal vazio. Dosimetria da pena. Aumento pelos maus antecedentes e regime mantido. Tratamento ambulatorial. Tese afastada. Ausência de comprovação. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJ-SP - APL: 30005689220138260653 SP 3000568-92.2013.8.26.0653, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:03/09/2015). Grifei.

"RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BICICLETA. OBJETO DE VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto de uma bicicleta, avaliada em R\$90,00 -, não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio inculcado no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e

restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau" (REsp. 828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5ª Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007, p. 654). Grifei.

Por fim, há de se pontuar, todavia, que o delito restou configurado na modalidade tentada, tendo em vista que os acusados foram detidos quando ainda estavam na prática delitiva, enquanto retiravam a terceira placa do equipamento, quando foram detidos pelos policiais.

Assim, resta claro que os réus não consumaram o delito por circunstâncias alheias à vontade deles, qual seja, a atuação dos policiais que os detiveram antes da efetiva consumação da subtração.

Desta forma, a prova colhida traz a certeza necessária para o decreto condenatório, restando comprovada a prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Com relação ao réu JACKSON SILVESTRE:

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, observo que o réu ostenta maus antecedentes, conforme demonstra a folha de antecedentes de fls. 36/50 e a certidão de fls. 55/58. Isso posto, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) acima no mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme a folha de antecedentes de fls. 36/50 e a certidão de fls. 55/58. Dessa forma, presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, portanto, aumento em mais 1/6 (um sexto) a pena fixada, somando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, fazendo presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que o réu tomou a posse de duas placas, estando a terceira sendo retirada, e somente não conseguiu consumir o delito, pois foi detido pelos policiais quando estava prestes a terminar a empreitada criminosa, de modo que por muito pouco o crime não se consumou, razão pela qual reduzo a reprimenda pela metade, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Considerando a reincidência do réu, este não atende aos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Considerando a reincidência do acusado, já possuindo, inclusive, várias condenações por crimes contra o patrimônio, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena aplicada.

Com relação ao réu CARLOS EDUARDO DE JESUS:

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, observo que o réu ostenta maus antecedentes, conforme demonstra a folha de antecedentes de fls. 25/35 e a certidão de fls. 51/54. Isso posto, aumento

a pena base em 1/6 (um sexto) acima no mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme a folha de antecedentes de fls. 25/35 e a certidão de fls. 51/54. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal. No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes. Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária - prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO - INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal. PENA - DOSIMETRIA - SOBREPOSIÇÃO - INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição - artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em mais 1/6 (um sexto) a pena fixada, somando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, fazendo presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que o réu tomou a posse de duas placas, estando a terceira sendo retirada, e somente não conseguiu consumir o delito, pois foi detido pelos policiais quando estava prestes a terminar a empreitada criminosa, de modo que por muito pouco o crime não se consumou, razão pela qual reduzo a reprimenda pela metade, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Considerando a reincidência do réu, este não atende aos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Considerando a reincidência do acusado, já possuindo, inclusive, várias condenações por crimes contra o patrimônio, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena aplicada.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus JACKSON SILVESTRE e CARLOS EDUARDO DE JESUS, qualificados nos autos, como incurso no

artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira. Os réus NÃO poderão recorrer em liberdade. Presos em flagrante e mantidos custodiados durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/0044481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 10/05/2021).

Recomendem-se os sentenciados na unidade prisional em que se encontram recolhidos. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta. Considerando que os sentenciados foram assistidos por advogada dativa nomeada por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que eles se encaixam no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo aos sentenciados os benefícios da Justiça Gratuita isentando-os do pagamento das custas processuais. Anote-se.

P.I.C.

Santos, 08 de novembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA